

1511969-64.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Carla de Oliveira Pinto Ferrari

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 20ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/07/2022

... CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO COM BASE NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS. REEXAME PROBATÓRIO. REDUÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PATAMAR DIVERSO DE 2/3. AUSÊNCIA DE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

20ª Vara Criminal

Av Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1511969-64.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1511969-64.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2134655/2022 - DISE- DEL.SEC.OSASCO, 25036432 - DISE- DEL.SEC.OSASCO, 2134655 - DISE- DEL.SEC.OSASCO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ADOLFO JUNIOR TESCH

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carla de Oliveira Pinto Ferrari

Vistos.

ADOLFO JÚNIOR TESCH, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incurso nas penas do artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/2006 c/c o artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, porque no dia 17 de maio de 2022, por volta das 10h, na Rua Andries Both, nº 97, Jaguaré, São Paulo - SP, transportava entre Estados, para fins de tráfico, 385 tijolos de maconha, com peso de 36,5 kg, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com a

determinação legal e regulamentar.

Em 20 de junho de 2022 houve a determinação para a notificação do réu e apresentação da defesa prévia (fls. 153/155).

O réu foi notificado (fls. 192/194) e apresentou defesa prévia (195/199), arrolando as mesmas testemunhas da acusação. A denúncia foi recebida (fls. 200/201) e o réu citado.

Durante a instrução processual foram ouvidas duas testemunhas arroladas em comum pelas partes e uma declarante arrolada pela defesa, sendo em seguida o réu interrogado. Não foram requeridas diligências pelas partes.

Em alegações finais, a representante do Ministério Público reportou-se ao contido nos autos, pedindo a condenação do réu nos termos da denúncia, mas com o afastamento da agravante da calamidade pública. Com relação às penas, pediu a elevação da pena-base, incidência da causa de aumento de pena do tráfico interestadual, concordou com a aplicação da causa de diminuição do artigo 33, §4º. da Lei nº 11.343/06 e a fixação do regime inicial fechado.

O Defensor requereu a manutenção das penas no mínimo legal, incidência da atenuante da confissão e afastamento da agravante da calamidade pública, a aplicação da causa de diminuição do artigo 33, 4º, da Lei nº 11.343/06 em seu grau máximo, aumento mínimo pela interestadualidade, regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

É o relatório do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão estatal é totalmente procedente.

Os policiais civis Onassis e Moisés disseram que foi recebida denúncia anônima no dia anterior aos fatos, na qual o denunciante informou que grande quantidade de droga seria transportada por meio de um caminhão, cujo emplacamento foi informado, e que a entrega ocorreria na Raposo Tavares, informando, ainda, que as drogas iriam para Osasco. Em viatura caracterizada, iniciaram campanha na rodovia citada, por volta das 22h do dia anterior. Permaneceram em campanha e por volta das 09h, o referido caminhão descrito passou pela referida rodovia, motivo pelo qual passaram a acompanhá-lo. Em dado momento, o veículo parou num pátio de estacionamento privado e lá permaneceu parado. Decidiram abordar o motorista. O réu informou que o caminhão era de sua propriedade e confirmou que estava transportando drogas, indicando onde estavam escondidas dentre a carga que era transportada. Ele informou que receberia entre R\$ 30.000 e 50.000 pelo transporte. Ele informou que havia carregado a droga em outro Estado. Ele estava sozinho no caminhão. Não o conheciam anteriormente.

A declarante Eliete disse que é ex-esposa do réu, estando dele separada desde 2018, sendo que foram casados por 17 anos. O casal teve dois filhos, de 20 e 17 anos.

Relatou o processo de aquisição do caminhão do réu, bem como as dificuldades financeiras que ele estava passando. Não tinha conhecimento direto sobre os fatos.

O réu, em seu interrogatório, confessou a prática delitativa. Disse que estava passando por dificuldades financeiras e que já havia recebido várias propostas para fazer transporte de drogas, sempre as rejeitando. Mas, diante das dificuldades enfrentadas, por ter dois filhos, acabou aceitando efetuar o transporte. O carregamento deu-se em Foz do Iguaçu, mas o interrogando não acompanhou a colocação da droga no caminhão. Receberia R\$ 50.000 pelo transporte e receberia o valor apenas após a entrega da carga.

Assim, é de se concluir pela existência da prática de tráfico pelo réu, o que se extrai da conjugação dos seguintes fatores: grande quantidade e forma de acondicionamento da droga, que estava em tijolos, típica forma de acondicionamento da droga para posterior fracionamento; a incompatibilidade entre a quantidade de drogas e a situação financeira do réu; o recebimento de denúncia anônima dando conta do transporte da droga; o fato de o caminhão estar registrado em nome do réu, que se encontrava sozinho no veículo; confissão do réu. Em caso análogo já decidiu o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“TESTEMUNHA - Tóxico - Depoimentos prestados por policiais - Validade -

Inexistência de razão concreta para suspeição - Relatos que merecem a normal credibilidade das testemunhas em geral - Interpretação do artigo 202 do Código de Processo Penal - Recurso não provido.

PROVA CRIMINAL - Tóxicos - Drogas apreendidas na residência da ré que não produziu qualquer prova de que não fossem de sua propriedade - Recurso não provido.
PROVA CRIMINAL - Tóxicos - Casa conhecida como local de venda de entorpecentes, quantidade e acondicionamento da droga apreendida que nenhuma dúvida deixam a respeito da destinação comercial do produto - Recurso não provido." (Ap. Crim. nº 247.848-3 - São Paulo - 6ª Câ. Crim. de "Julho/98" - Rel. Debatin Cardoso - J. 13.08.98 - v.u).

Os policiais ouvidos procederam a relatos detalhados, uníssonos e harmônicos entre si, ratificando o que disseram em sede policial, nada havendo nos autos que possa extrair a validade de suas palavras. Trata-se de agentes públicos, dotados de fé pública, aos quais são conferidos poderes para fins de polícia preventiva e repressiva, não sendo razoável que, apenas em Juízo, suas declarações sejam recebidas sem o devido valor. Neste sentido:

"PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO COM BASE NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS. REEXAME PROBATÓRIO. REDUÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PATAMAR DIVERSO DE 2/3. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. ILEGALIDADE. CUMPRIMENTO DA PENA. REGIME INICIAL MAIS RIGOROSO. RÉU PRIMÁRIO. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. GRAVIDADE ABSTRATA. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. REDIMENSIONAMENTO. (...)

2. O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso" (STJ, HC 165561 / AM, rel. Min. NEFI CORDEIRO, j. 02/02/2016)

Observe que as pequenas contradições havidas em seus depoimentos apenas denotam que prestaram declarações verdadeiras, sem que tenha havido prévio ajuste, sendo certo que as contradições havidas dizem respeito a pontos marginais e não essenciais à diligência.

Ademais, o próprio réu confessou o tráfico de drogas, o que se encontra em conformidade com os demais elementos de prova.

Ainda que se argumente não terem os policiais presenciado a efetiva comercialização, irrelevante tal aspecto, haja vista que se trata de crime de conteúdo múltiplo ou variado, sendo que no presente caso trazia as porções de maconha.

A substância entorpecente apreendida foi submetida a exame pericial que comprovou seus efeitos tóxicos (fls. 96/98), também a corroborar o contido na denúncia. Com relação à majorante descrita na denúncia, reputa-se que deva ser acolhida. Com efeito, os policiais narraram que a denúncia anônima indicava que o deslocamento do caminhão de placas LZR-7114, a partir de outro Estado da Federação e que tinha como destino o Estado de São Paulo, sendo que o próprio réu confessou tal itinerário. Ademais, o documento de fls. 82/87 comprova que de fato o carregamento deu-se em outro Estado da Federação. Houve, portanto, a transposição da fronteira estadual, de forma que não há dúvida de que se tratou de um transporte interestadual, muito embora a jurisprudência seja no sentido de que sequer há necessidade de efetiva transposição da fronteira para a incidência da majorante, conforme a Súmula 587 do C. Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, quanto à agravante da calamidade pública descrita na denúncia, muito embora esta magistrada viesse reconhecendo a sua incidência em todos os crimes praticados desde a edição do Decreto que reconheceu tal situação no país, após inúmeras reformas de suas decisões pelo E. TJSP e também pelo E. STJ, admite-se ser o caso de se curvar ao entendimento superior para se evitar recursos desnecessários. Com efeito, os tribunais fixaram o entendimento quase pacífico no sentido de que há necessidade de demonstração de nexo causal entre a conduta do réu e a calamidade pública decorrente da pandemia, devendo haver demonstração concreta de que o acusado se valeu de tal situação para cometer o crime. Tal não ocorre nos presentes autos, de modo que não é o caso de se reconhecer a incidência da agravante em questão.

Forçosa, destarte, a condenação do réu nos termos acima mencionados. Passo à DOSIMETRIA DA PENA.

Observando-se os elementos norteadores contidos nos artigos 59 e 60 do Código Penal e ainda o artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, as penas permanecem no mínimo legal, eis que ausentes circunstâncias judiciais a serem consideradas nesta oportunidade. A quantidade de droga será utilizada na terceira fase da dosimetria, não sendo viável que possa ser utilizada em dois momentos, para aumento da pena-base e para basilar o redutor, sob pena de configuração de bis in idem, conforme recente orientação do E. STJ

Na segunda fase, ausentes agravantes e presente a atenuante da confissão espontânea, as penas permanecem no mínimo legal, sendo inviável a redução aquém deste patamar, conforme Súmula 231 do C. Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase, presente a causa de aumento pelo tráfico interestadual, de rigor a sua elevação no patamar mínimo, ficando as penas em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Ato contínuo, as penas devem ser reduzidas em 1/6, em atenção ao artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/2006, que inovou ao estabelecer causa de diminuição de pena calcada na primariedade e bons antecedentes do acusado que não se dedique às atividades criminosas e não integre organização criminosa. No presente caso deve-se ter em conta que, a despeito da sua primariedade, transportava substancial quantidade de maconha, a indicar que seus fornecedores têm poder econômico, já que tal quantidade de droga tem custo elevado, não havendo qualquer demonstração de que o réu tivesse, por si só, condições econômicas de adquirir tal quantidade de maconha, restando evidente sua ligação inicial com tal atividade ilícita, mas já com traficantes com poder econômico elevado, o que, sabe-se, existe apenas no crime organizado. Não há como se negar que o réu tinha ciência acerca da quantidade de droga que transportava, muito embora alegue que não presenciou o momento em que a droga foi carregada. Isto porque, tinha ciência do peso efetivo da carga legal que estava a transportar, sendo de conhecimento público e notório que caminhões são submetidos a pesagem durante as viagens que realizam, de forma que, diante do peso efetivamente apresentado e aquele que deveria existir, tinha o réu ciência da efetiva quantidade de droga transportada. Logo, muito embora faça jus ao tráfico privilegiado, entendo que as circunstâncias acima indicadas justifiquem a sua aplicação no patamar mínimo de 1/6, tornando-se as penas definitivas em 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa, no mínimo legal.

Nestes sentidos, vejam-se os seguintes julgados:

"A Terceira Seção acolheu a proposta de afetação dos REspS 1.963.433/SP, 1.963.489/MS e 1.964.296/MG ao rito dos recursos repetitivos, a fim de uniformizar o entendimento a respeito da seguinte controvérsia: Isoladamente consideradas, a natureza e a quantidade do entorpecente apreendido, por si sós, não são suficientes para embasar conclusão acerca da presença das referidas condições obstativas e, assim, afastar o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado (ProAfr no REsp 1.963.433-SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Seção, por unanimidade, julgado em 03/05/2022, DJe 09/05/2022. - Tema 1154)".

"(...) 1. No caso, encontra-se justificada a redução de 1/6 da pena por incidência da minorante prevista no art. 33 §4º, da Lei de Drogas, não se constatando ilegalidade na dosimetria então fixada, tendo em vista a quantidade, natureza e variedade das drogas apreendidas. Sendo assim, não é possível desconsiderar a valoração negativa dos referidos vetores, não utilizados para elevação da pena base, ou mesmo aumentar o quantum de redução da pena, como pretende a defesa. 2. É possível a "[...]valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos, desde que não tenham sido considerados na primeira fase do cálculo da pena" (HC n. 725.534/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 1º/6/2022). 3. Agravo regimental desprovido" (AgRg no HC n. 742.937/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022).

"As circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena, sob pena de bis in idem" (STF. Plenário. ARE 666334 RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 03/04/2014 (Repercussão Geral – Tema 712)).

Ante a primariedade do réu e a quantidade de pena, fixo o regime inicial semiaberto como inicial para o cumprimento, em conformidade com o disposto no artigo 33, §2º, alínea "b", do Código Penal.

As condições econômicas do réu são modestas, assim fixo o valor de cada dia-multa no piso legal.

Deixo de aplicar o artigo 387, § 2º do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 12.736/2012, por entender que tal dispositivo é impossível de ser aplicado no Juízo de primeiro grau. A progressão de regime é matéria atinente ao Juízo das execuções criminais, devendo ser aferido não apenas o tempo de cumprimento da pena, como também se o sentenciado possui mérito para a progressão. Além disso, considero tal dispositivo inconstitucional, uma vez que viola os princípios da isonomia e da individualização da pena. Ao se considerar somente o tempo de prisão provisória para a fixação do regime inicial, aquele que ficou solto durante o processo é tratado de forma prejudicial com relação àquele que ficou preso, uma vez que este poderá ter direito ao regime inicial mais benéfico tendo como base apenas o tempo de pena cumprido provisoriamente.

Ante todo o exposto e o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para o fim de CONDENAR o réu ADOLFO JUNIOR TESCH, por infração ao artigo 33, caput, c/c § 4º e com o artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/06, às penas de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa, no mínimo legal.

As mesmas razões que recomendaram a custódia do acusado no curso do feito permanecem ainda presentes, vendo-se ainda reforçada a necessidade da cautela uma vez que, determinada a imposição de elevada pena ao acusado, patente o risco de que solto venha procurar obstar a aplicação da lei penal, pondo-se em fuga. Deixo de lhe facultar, assim, o recurso em liberdade. Recomende-se o réu no estabelecimento em que se encontra recolhido.

Com o trânsito em julgado, lance-se o seu nome no rol dos culpados e expeça-se o necessário.

Quanto ao veículo apreendido, decreto o seu perdimento em favor da União, nos termos do artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal, e artigo 63, inciso I e §1º, da Lei nº 11.343/06, haja vista que, proprietário do caminhão e do semirreboque (fls. 45/49 e 59), transportava relevante quantidade de droga escondida no meio da carga legítima de polipropileno, restando evidente a sua utilização para o tráfico de drogas.

Custas na forma da lei.

Oficie-se para destruição das drogas apreendidas.

Oficie-se à SAP para que seja autorizada sua transferência para unidade prisional mais próxima de sua família, caso haja manifestação favorável do Juízo da VEC e disponibilidade para tanto, não havendo mais qualquer óbice por parte deste Juízo. P.R.I.

São Paulo, 27 de julho de 2022.

CARLA DE OLIVEIRA PINTO FERRARI
Juíza de Direito

MARGEM DIREITA